

次の【見解】は、実体的には常習特殊窃盗罪を構成する窃盗行為が刑法第235条の窃盗罪（以下「単純窃盗罪」という。）として起訴され（以下「前訴」という。）、判決が確定した後、その判決の宣告前に犯されていた余罪の窃盗行為（実体的には確定判決を経由した窃盗行為と共に一つの常習特殊窃盗罪を構成するもの）が、前同様に単純窃盗罪として起訴された場合（以下「後訴」という。）に、前訴の確定判決の一事不再理効が後訴に及ぶかという点に関するものである。後記1から5までの【記述】のうち、【見解】と同じ立場から論じているものはどれか。

【見 解】

訴因制度を採用した現行刑事訴訟法の下においては、少なくとも第一次的には訴因が審判の対象であると解されること、犯罪の証明なしとする無罪の確定判決も一事不再理効を有することに加え、常習特殊窃盗罪の性質や一罪を構成する行為の一部起訴も適法になし得ることなどに鑑みると、前訴の訴因と後訴の訴因との間の公訴事実の単一性についての判断は、基本的には、前訴及び後訴の各訴因のみを基準としてこれらを比較対照することにより行うのが相当である。本件においては、前訴及び後訴の訴因が共に単純窃盗罪であって、両訴因を通じて常習性の発露という面は全く訴因として訴訟手続に上程されておらず、両訴因の相互関係を検討するに当たり、常習性の発露という要素を考慮すべき契機は存在しないのであるから、ここに常習特殊窃盗罪による一罪という観点を持ち込むことは、相当でないというべきである。

【記 述】

1. 単純窃盗として起訴された以上、訴因を動かす権限のない裁判所としては、訴因の範囲において審判すべきである。
2. 裁判所は訴因を超えて事実を認定し有罪判決をすることは許されないが、免訴や公訴棄却といった形式裁判をする場合に関する限り訴因に拘束されることはないと解すべきである。
3. 両訴因間における公訴事実の単一性の有無を判断するに当たり、いずれの訴因の記載内容にもなっていないところの犯行の常習性という要素について証拠により心証形成をし、両者は常習特殊窃盗として包括的一罪を構成するから公訴事実の単一性を肯定できる場合には、前訴の確定判決の一事不再理効が後訴にも及ぶとすべきである。
4. 実体に合わせて訴因が変更されれば免訴となるが、そうでなければ有罪判決になるということになり、検察官の選択によって両極端の結果を生じさせるのは、不合理である。
5. 訴因は有罪を求めて検察官により提示された審判の対象であり、訴因を超えて有罪判決をすることは、被告人の防御権を侵害するから許されないが、これに対し、確定判決の有無という訴訟条件の存否は職権調査事項である上、その結果免訴判決がなされても、被告人の防御権を侵害するおそれは全くないから、訴因に拘束力を認める理由も必要性も存しない。

（参照条文）盗犯等の防止及び処分に関する法律（改）

第2条 常習トシテ左ノ各号ノ方法ニ依リ刑法第235条、第236条、第238条若ハ第239条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニ対シ窃盜ヲ以テ論ズベキトキハ3年以上、強盜ヲ以テ論ズベキトキハ7年以上ノ有期拘禁刑ニ処ス

一 凶器ヲ携帯シテ犯シタルトキ

二 2人以上現場ニ於テ共同シテ犯シタルトキ

三 門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ又ハ鎖鑰ヲ開キ人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ艦船ニ侵入シテ犯シタルトキ

四 夜間人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ艦船ニ侵入シテ犯シタルトキ

一事不再理効は、公訴事実の同一性・単一性の範囲に及ぶ。審判の対象は訴因であるが、公判手続において公訴事実の同一性の範囲で訴因変更が許され（312条1項）、その範囲で有罪とされる危険が生じるからである。前訴の訴因と後訴の訴因とを比較対照し常習一罪の関係にあれば、公訴事実が単一といえるため、一事不再理効が及ぶことになる。そこで、実体的には常習特殊窃盗を構成するとみられる数個の窃盗行為が、前訴において単純窃盗として判決を受け、後訴においても単純窃盗として起訴された場合に、一事不再理効が及ぶかが問題となる。本問【見解】は、この点についての、判例（最判平15.10.7、百選95事件）の見解である。【見解】は、①公訴事実の単一性の判断については基本的には訴因のみを基準として比較対照することによって行う、②訴因の設定に関しては検察官が訴追裁量権を有しているのだから、裁判所はその範囲内で審判を行うことになるのであり、③訴因において常習性の発露が存在しない以上は、裁判所は常習特殊窃盗罪による一罪という観点を持ち込むことはできない、したがって、一事不再理効は及ばない、というものである。

1 同じ立場から論じている

【見解】は、上記②のとおり、裁判所は検察官の設定した訴因の範囲内で審判するものとしている。そして、本記述は、裁判所は訴因を動かす権限がなく、検察官が設定した訴因の範囲内で審判すべきである、としている。したがって、本記述は、【見解】と同じ立場から論じているといえる。

2 異なる立場から論じている

【見解】によると、上記①②のとおり、裁判所は検察官の設定した訴因を比較して両訴因が一罪の関係にあれば、公訴事実が単一であるとして一事不再理効が及び、免訴といった形式裁判をすることになる（337条1号）。すなわち、形式裁判の場合も、検察官の設定した訴因を基準に公訴事実の単一性を判断するのであって、裁判所は訴因に拘束される。よって、本記述は、形式裁判をする場合に関する限り訴因に拘束されることはないとしている点で、【見解】と異なる立場といえる。

3 異なる立場から論じている

【見解】は、上記③のとおり、裁判所は、訴因において常習性の発露が存在しない以上は常習特殊窃盗罪による一罪という観点を持ち込むことはできない、というものである。本記述は、訴因において常習性の発露が存在しないにもかかわらず、証拠によって心証形成し、常習一罪という観点を持ち込んでよいとするものである。したがって、本記述は、【見解】とは異なる立場といえる。

4 異なる立場から論じている

【見解】の立場によると、実体に合わせて訴因が常習特殊窃盗罪に変更されれば、前訴と後訴の訴因との間に公訴事実の単一性が認められるため、一事不再理効が及び、後訴は免訴（337条1号）となる。他方で、訴因変更がされなければ、一事不再理効は及ばず有罪判決となる。そうすると、検察官の選択によって両極端の結果を生じさせることになるため、本記述のような批判がなされることになる。したがって、本記述は、【見解】への批判であり、異なる立場からの論述といえる。

5 異なる立場から論じている

【見解】は、上記②のとおり、確定判決の有無という訴訟条件について、裁判所は検察官の設定した訴因の範囲内で審判すべきものとするものである。したがって、本記述は、訴因に拘束力を認める理由はないとしている点で、【見解】と異なる立場といえる。